

1500484-31.2020.8.26.0004

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... destinavam-se inequivocamente ao tráfico de drogas. Segundo o apurado, nas circunstâncias acima delineadas, Policiais Civis realizavam diligências no âmbito da operação "Narco Brasil", na comunidade do "Mata Porco", em locais previamente levantados como possíveis pontos de venda de drogas. Num dos pontos de tráfico, os investigadores localizaram ALISSON que, por esta em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

Processo nº: 1500484-31.2020.8.26.0004 - C. 2021/000788 - Fls.

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500484-31.2020.8.26.0004 - C. 2021/000788

Réu:

RICARDO MATIAS DE PAULA

Aos 04 de abril de 2022, às 14:20h, na sala de audiências da 12ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Marcos Fleury Silveira de Alvarenga, comigo escrevente a seu cargo, a final assinado, regularmente conectados à sala virtual, foi aberta a audiência, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, por meio de videoconferência criada no software Microsoft Teams, com a concordância das partes. Aberta, com as formalidades legais, observou-se no lobby da sala virtual, tendo se verificado a exitosa conexão do representante do Ministério Público, na pessoa da Dra. CLÁUDIA PORRO, presente o réu RICARDO MATIAS DE PAULA, qualificado em apartado, a defesa na pessoa da Dra. PAULA FREITAS DA SILVA, OAB/SP 302.157, e as testemunhas JAIRO XAVIER DA SILVA JUNIOR, RE nº 155306-2 e FRANCISCO SOARES DA COSTA FILHO, RE nº 113.331-4. Abertos os trabalhos, foi colhido pelo sistema de captação de áudio e vídeo o depoimento da * vítima e testemunhas de acusação e, em seguida, foi o réu interrogado, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, sendo a ele dada a oportunidade de se entrevistar reservadamente com seu defensor antes da realização do ato. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que: Indagado às partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, declaro encerrada a Instrução e dou a palavra às partes para alegações finais.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, pela mesma foi dito: ALISSON XAVIER DOS SANTOS como incurso no art. 33 "caput" da Lei 11.343/06 porque, no dia 21 de junho de 2021, por volta das 15h, na Rua José de Castro Lima Filho, altura do nº 120, Parque São Lucas, nesta cidade e Comarca porque trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 09(nove) invólucros plásticos contendo tetrahydrocannabinol, com peso líquido de 28,1g (vinte e oito gramas e um

decigrama), e 44 (quarenta e quatro) invólucros (ependorfs) contendo cocaína sob a forma de crack, com peso líquido de 6,8g (seis gramas e oitodecigramas), conforme auto de exibição apreensão a fls. 07 e laudo de constatação a fls. 23/26, as quais ante as circunstâncias da apreensão destinavam-se inequivocamente ao tráfico de drogas. Segundo o apurado, nas circunstâncias acima delineadas, Policiais Cíveis realizavam diligências no âmbito da operação "Narco Brasil", na comunidade do "Mata Porco", em locais previamente levantados como possíveis pontos de venda de drogas. Num dos pontos de tráfico, os investigadores localizaram ALISSON que, por esta em lugar suspeito, foi abordado. Durante a abordagem, os agentes revistaram uma pochete preta que o indiciado tra zia às mãos e, em seu interior, foram encontradas porções de maconha e crack, embaladas, prontas para venda e distribuição, além de R\$130,00 (cento e trinta reais) em notas trocadas. Diante disto, o acusado foi preso em flagrante delito e conduzido até a Delegacia de Polícia, onde, interrogado, permaneceu em silêncio (fls. 16). A quantidade e variedade de entorpecentes, a forma como estavam acondicionados, bem como a apreensão de dinheiro em notas trocadas, demonstram, de maneira inequívoca, a prática do delito de tráfico de drogas pelo denunciado. Devidamente citado, apresentou resposta escrita. Ao longo da instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, procedendo-se ao interrogatório. É o breve relato. A presente ação penal PROCEDE. A materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência a fls. 02/04, pelo auto de exibição e apreensão a fls. 07, laudo de constatação a fls. 23/26 e notadamente pelo laudo de exame químico toxicológico a fls. 124/125 que fazem certo ser cocaína a substância apreendida (fls. 107). Não restam dúvidas, quanto a autoria. O réu manteve-se em silêncio na fase policial. Perante o Juízo disse que é verdade que estava com as drogas e a quantia em dinheiro e é verdade que estava "segurando" a bolsa sozinho. Tinha comprado as drogas que é era quantidade alta. Iria passar para outra pessoa as drogas. Tal confissão restou corroborada pelas demais provas coligidas. O Policial Civil Admilson Torres da Silva declarou que no dia dos fatos saíram para apurar o tráfico de drogas. Na réu que o réu foi preso há bastante ocorrência de tráfico. Ingressaram numa viela e mais à frente abordaram ALISSON que possuía uma pochete com drogas dentro e ele foi levado ao Distrito. Salvo engano tinha eppendorfs com crack e um pouco de maconha, além de R\$ 130,00. No local da abordagem e no Distrito o réu nada falou. Tinha dois policiais na diligência. Recordar-se do réu de "passagem". O local não tem muitos usuários, eles pegam a drogagem e vão embora. Não conhecia muito bem a região. O Policial Civil Thiago Luiz Zan declarou que no local, uma comunidade, tem um ponto de tráfico de drogas. Entrou andando normal no beco e o réu estava com uma pochete e valor e foi preso em flagrante e levado à Delegacia. Ele estava sozinho. Tinha maconha, cocaína e Crack e R\$ 130,00. Ele falou "perdi, perdi" ou algo assim. Quando prendem alguém, há outro traficante no mesmo dia. As vezes o olheiro falha. Ante todo o exposto, aguarda a Promotoria de Justiça seja a presente ação penal julgada inteiramente PROCEDENTE, CONDENANDO-SE o réu como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06. Na dosagem da pena, aguarda-se a consideração dos maus antecedentes e reincidência do réu por roubo.

Dada a palavra à Dra. Defensora, pela mesma foi dito: pretende a Douta Promotoria, imputar ao acusado as sanções dos art. 33 da Lei n. 11.343/06 cc. Art. 273 p. 1ºB, I, em concurso material conforme fatos que constam na denúncia. A pretensão é improcedente, eis que não vieram para os autos prova cabal, segura e extensa de dúvidas, de ter o acusado, cometido os crimes capitulados na exordial. As provas trazidas pela acusação, não autorizam a condenação do acusado nos artigos elencados na exordial, pois, permissa venia, o acusado aqui em juízo, informa a verdade real dos atos a Vossa Excelência, conforme seu depoimento acostado aos autos. O tráfico também não ficou demonstrado, porque, embora demonstrada a natureza da substância apreendida no exame químico-toxicológico realizado, as provas, não demonstram certeza quanto a autoria, tampouco sobre a destinação imputada na denúncia, de que o acusado a tinha "para venda". A forma da apreensão da droga e local onde estavam as mesmas, desacompanhadas de outro elemento de convicção, é insuficiente para provar o exercício dos verbos guardava e mantinha em depósito ou a tinha para

venda. Desse modo, tais elementos, não se prestam a demonstrar o propósito de mercancia, assim, os fatos não autorizam a condenação do denunciado como traficante. Sobre o delito de vender medicamento sem registro no órgão competente, devemos diferenciar um produto com registro suspenso, do produto efetivamente sem registro. O praguicida encontrado em poder do acusado possui registro no órgão competente, entretanto, este encontra-se suspenso. Ampliar-se o sentido da expressão "registro suspenso" para abranger as situações de ausência de registro trata-se de verdadeira analogia in malam partem, instituto proibido de ser aplicado em matéria de direito penal. Entretanto, caso não seja esse o entendimento de V. Excelência, deve-se reconhecer que o acusado agiu em erro, mais precisamente o erro sobre a ilicitude do fato ou erro de proibição (direto), que ocorre sempre que o agente supõe praticar uma conduta legal ou legítima, mas que em verdade configura ilícito penal. Há erro de proibição sempre que o autor carecer da consciência da ilicitude do fato, ou, como diz Francisco de Assis Toledo, há erro de proibição quando o agente realiza uma conduta proibida, seja por desconhecer a norma proibitiva, seja por conhecê-la mal, seja por não compreender o seu verdadeiro âmbito de incidência, sendo nesse caso isento o acusado, por se tratar de erro inevitável. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, de rigor esclarecer que o STF decidiu que é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.677 /1998 - reclusão de 10 a 15 anos - à hipótese prevista no seu parágrafo 1º-B, inciso I, que versa sobre medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica reprimido o preceito secundário do artigo 273, na redação originária - reclusão de um a três anos e multa", devendo este último ser considerado. No entanto, se ainda assim não entender V. Excelência, de rigor ressaltar que o acusado PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES COM RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA, SENDO QUE SEMPRE FOI TRABALHADOR, devendo, em caso de condenação, ser reconhecido o tráfico privilegiado, com a aplicação do redutor máximo previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, de modo que reduza a reprimenda do tráfico inerente ao apelante, pois o acusado não se dedica a atividade criminosa, tampouco integra organização de tal natureza, ademais, atividade criminosa requesta maus antecedentes e habitualidade. Por todo o exposto, e mais que o notável saber jurídico de Vossa Excelência defluir do caso, espera a defesa, seja o réu absolvido das imputações que ora lhe pesam, por insuficiência de provas, requerendo, requer-se a liberação dos aparelhos telefônicos e documentos pessoais do acusado que foram apreendidos. Caso não seja esse o entendimento de V. Excelência, requer-se o reconhecimento do tráfico privilegiado com a aplicação do maior redutor de pena; substituição por pena restritiva de direitos ou quando não a fixação do regime aberto; reconhecimento da inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273; e ainda o direito de apelar em liberdade, pois só assim, cristalizar-se-á o Brocardo latim que diz "in dubio pro reo" distribuindo-se ainda mais os ditames de J U S T I Ç A.

Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: Vistos. RICARDO MATIAS DE PAULA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e artigo 273, §§ 1º, 1º-A e 1º-B, inciso I, na forma do artigo 69 (concurso material), do Código Penal, porque no dia 25 de setembro de 2019, por volta das 15hs30min, na rua Guaicurus, altura do número 1500, Lapa, nesta cidade, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 11 invólucros plásticos contendo cocaína (fls. 6/8, 16/18); constando ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, que tinha em depósito para vender e de qualquer forma entregar a consumo de terceiros, produto destinado a fins terapêuticos e medicinais, consistente em saneante, sem o registro exigível pelo órgão de vigilância sanitária competente, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 6/8 e laudo pericial de fls. 91/95. Recebida a denúncia, citado, apresentou defesa preliminar. Mantido o recebimento da denúncia, durante a instrução criminal ouvidas as testemunhas de acusação, afinal interrogado o réu. Em alegações finais manifestou-se o Ministério Público pela procedência da ação penal, uma vez demonstradas a autoria e materialidade delitiva. A Defesa, a seu turno, pugnando

pela absolvição, para tanto apontou a fragilidade do conjunto probatório; em caso de entendimento diverso, que acolhidas as demais teses. É o relatório. Decido. A ação penal é parcialmente procedente em relação ao crime do artigo 273, do CP, sendo improcedente em relação ao crime de tráfico de entorpecentes. Com efeito, finda a instrução criminal, a materialidade restou fartamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/5, auto de exibição e apreensão de fls. 6/8 e laudo pericial de fls. 92/98. Igualmente, a autoria é inconteste, não só pelo teor das provas colhidas na fase inquisitiva, quanto pela prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, em tudo demonstrando a venda/comércio ilícito de produtos sem registro no órgão de vigilância sanitária competente. Também não há que se falar em ofensa ao princípio da ofensividade, que exigiria da conduta, concretamente, lesão ou risco ao bem jurídico. De fato, tratando-se de crime de perigo abstrato, é plenamente dispensável que tenha ocorrido dano concreto à saúde de eventuais usuários das substâncias, bastando a prática de uma das condutas descritas no artigo 273, do CP, pois o legislador estabeleceu uma presunção legal absoluta de perigo para a saúde pública. Neste sentido, Nucci explica que “não há qualquer inconstitucionalidade em admitir o perigo abstrato, que é fruto da experiência auferida pelo legislador, passada à elaboração do tipo penal, prerrogativa sua e não do Poder Judiciário. Foge assim e dever-se-ia exigir, igualmente, perigo concreto de todas as infrações de perigo, pois, se a presunção não pode ser válida para um determinado tipo incriminador, também não deve sê-lo para os demais” (in Código Penal Comentado, 11ª Ed., pg. 1062). Tampouco deve ser acolhido pleito de desclassificação para a modalidade culposa do crime. Além do mais, pouco importa se os produtos eram autênticos. Tratando-se de crime de perigo abstrato, a lesão ou o risco de lesão são igualmente presumidos. Assim, devidamente demonstradas a autoria e materialidade delitiva e não prosperando as teses defensivas em quaisquer de seus outros aspectos, de rigor a condenação do réu pelo crime pelo qual denunciado. Por fim, com relação à alegação da inconstitucionalidade do artigo 273, do CP, primeiramente, não se pode perder de vista que o legislador, ao editar a Lei nº 9.677/98, estabeleceu relevantes modificações ao referido dispositivo ao introduzir novos núcleos de tipificação do crime, a fim de impor maior controle à venda de medicamentos, tendo em vista a proteção da saúde pública. Ocorre que a pena mínima de 10 anos imposta pelo legislador mostra-se flagrantemente desproporcional, ainda mais considerando que se trata de crimes de perigo abstrato e, ainda levando-se em conta figuras penais análogas, como o crime de tráfico ilícito de entorpecente. Assim, impõe-se ao Judiciário a adequação da pena cominada ao crime em tela, inclusive porque já fruto de arguição de inconstitucionalidade neste Tribunal, que entendeu inconstitucional o preceito secundário do artigo sob exame: “Arguição de inconstitucionalidade. Alegação de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal. Conhecimento. Morte do interessado no curso da revisão criminal que não leva à sua extinção. Inteligência do art. 631 do Código de Processo Penal. Verificação da desproporcionalidade do preceito secundário do dispositivo impugnado, especialmente se comparado a delitos semelhantes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Arguição julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da pena do art. 273, § 1º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal” (TJSP, Arguição de Inconstitucionalidade nº 0052451-46.2016.8.26.0000, Rel. designado Des. Márcio Bartoli, j. 28.6.2017). No mesmo sentido, concluiu a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Arguição de inconstitucionalidade. Preceito secundário do art. 273, § 1º-B, V, do CP. Crime de ter em depósito, para venda, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada. Ofensa ao princípio da proporcionalidade. A intervenção estatal por meio do Direito Penal deve ser sempre guiada pelo princípio da proporcionalidade, incumbindo também ao legislador o dever de observar esse princípio como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. É viável a fiscalização judicial da constitucionalidade dessa atividade legislativa, examinando, como diz o Ministro Gilmar Mendes, se o legislador considerou suficientemente os fatos e prognoses e se utilizou de sua margem de ação de forma adequada para a proteção suficiente dos bens jurídicos fundamentais. Em atenção ao

princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos (CF, art. 5º, LIV), é imprescindível a atuação do Judiciário para corrigir o exagero e ajustar a pena cominada à conduta inscrita no art. 273, § 1º-B, do Código Penal. O crime de ter em depósito, para venda, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada é de perigo abstrato e independe da prova da ocorrência de efetivo risco para quem quer que seja. E a indispensabilidade do dano concreto à saúde do pretense usuário do produto evidencia ainda mais a falta de harmonia entre o delito e a pena abstratamente cominada (de 10 a 15 anos de reclusão) se comparado, por exemplo, com o crime de tráfico ilícito de drogas - notoriamente mais grave e cujo bem jurídico também é a saúde pública. A ausência de relevância penal da conduta, a desproporção da pena em ponderação com o dano ou perigo de dano à saúde pública decorrente da ação e a inexistência de consequência calamitosa do agir convergem para que se conclua pela falta de razoabilidade da pena prevista na lei. A restrição da liberdade individual não pode ser excessiva, mas compatível e proporcional à ofensa causada pelo comportamento humano criminoso. Arguição acolhida para declarar inconstitucional o preceito secundário da norma" (AI no HC 239.363, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.02.2015). Conquanto este julgado trate apenas do inciso V, do referido dispositivo legal, percebe-se que o acórdão se referiu ao tema de forma genérica. Dessa forma, conforme exposto acima, na esteira do entendimento desta E. Corte e do Colendo STF, ao declararem a inconstitucionalidade da pena (preceito secundário) do artigo 273, § 1º-B, adoto, em sua substituição, a reprimenda prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, qual seja, reclusão de 05 a 15 anos e pagamento de 500 e 1500 dias-multa, até porque ambos os delitos têm por escopo a tutela da saúde pública e merecem o mesmo juízo de reprovabilidade. Todavia, em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, entendendo frágil a prova a autorizar uma condenação; isto, pois, além de afinal em poder do réu não apreendida substâncias entorpecentes em quantidade a por si só indicarem certo destino ao ilícito comércio, também não observado com a necessária certeza em condição/circunstância indicativa de tráfico de entorpecentes. Passo a dosar a pena. Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, culpabilidade normal à espécie, personalidade, primariedade (fls. 137/138), circunstâncias e consequências delitivas, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, observo que não incide a reprimenda anteriormente fixada qualquer outra causa de aumento, entretanto, deve ser observada a causa especial de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Diante disso, atento as condições e circunstâncias subjetivas e objetivas acima indicadas, em especial, ao montante de produtos apreendidos, reduzo a pena cominada de 2/3, tornando-a definitiva em um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal. Considerada a pena aplicada, nos termos do artigo 33, § 1º, c, e § 3º, do Código Penal, fixo o regime aberto para início do cumprimento de pena. Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 125/127 para condenar o réu RICARDO MATIAS DE PAULA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 273, §§ 1º, 1º-A e 1º-B, inciso I, do Código Penal, à pena de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal; absolvendo-o de também incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 (concurso material), do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Faculto ao réu eventual recurso em liberdade. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral para cumprimento do quanto disposto nos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral c.c. o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Publicada em audiência, registre-se e cumpra-se. Neste ato, sem recurso das partes e réu, certifique-se o trânsito em julgado, expedindo-se guia de recolhimento e ofícios de estilo, designando-se audiência de advertência. Após, arquivem-se. Saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim assinado. Nada mais. Eu, _____ ROGERIO ALVES DA SILVA, digitei.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

Link de acesso à gravação das mídias captadas, armazenadas pelo Sistema OneDrive:
(copiar e colar no navegador)

[https://tjssp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rogeriod_tjssp_jus_br/
Erq_eZPsf0tBh0Nv20D7vu0BQxn0TAEYjYsox07heiE4xw?e=x4p3mK](https://tjssp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rogeriod_tjssp_jus_br/Erq_eZPsf0tBh0Nv20D7vu0BQxn0TAEYjYsox07heiE4xw?e=x4p3mK)